

0015579-19.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Rubens Hideo Arai

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ao cliente acerca do furto, roubo ou golpe ocorrido e pelo fato carregar consigo as senhas bancárias. O efeito disso seria desamparar quem é verdadeiramente hipossuficiente nas relações de consumo. Entendimento consolidado no REsp. 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, conforme entendimento do STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11)

3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana1jec@tjsp.jus.br

Autos nº

0015579-19.2022.8.26.0001

Requerente:

Neide Poim Brioli

Requerido:

Banco Originial S/A e outro

Vistos.

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado. As partes foram devidamente intimadas (fl. 20) para que fundamentassem o interesse na produção de prova em audiência e fornecessem o endereço eletrônico das testemunhas que pretendiam ouvir, tendo a autora deixado transcorrer in albis o prazo concedido e os réus feito protesto genérico por provas descumprindo referido despacho. Assim, a prova passou a ser de natureza documental e deveria instruir a inicial e a defesa e que admite julgamento antecipado na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil. Afasto a preliminar de ilegitimidade da parte, pois de acordo com a Teoria da Asserção, esta decorre da titularidade dos interesses em conflito e deve ser analisada de forma abstrata, desvinculada de apreciação probatória e da discussão acerca do mérito. Considerando que a parte autora, na petição inicial, atribuiu à parte ré a responsabilidade pelo fato que considera danoso, esta é legítima para responder à demanda. A discussão sobre a efetiva existência de responsabilidade corresponde ao mérito e não representa objeção processual, na medida em que "(...) As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito" (STJ - 3ª T. - REsp 1.424.617/

RJ - Rel^a. Min^a. Nancy Andrichi - j. 06.05.2014 - DJe 16.06.2014).

No mérito, temos que em relação ao Facebook, temos que examinando a conversa de fl. 15, verifica-se que a nora da autora, Sra. Margareth foi quem acabou fornecendo todos as informações para o estelionatário. Veja que ele manda uma mensagem para ela sem mencionar o nome da mesma e sem fornecer o próprio. É como se nós colocássemos um número de forma aleatória para mandar a mensagem inicialmente enviada (fl. 15), que se aplica para toda e qualquer pessoa. Ela acaba presumindo ser o filho e informa que a autora (a avó) teria dinheiro para emprestar porque dias antes havia feito pagamento para ela no aplicativo e viu que ela tinha saldo no banco. O estelionatário vai falando genericamente, sem mencionar o nome de ninguém, nem o grau de parentesco, mas a nora vai falando do pai e da avó, e o nome dela. É a nora quem faz a intermediação e, sem querer, viabiliza o golpe. Não há qualquer elemento que indique que o número da nora foi fornecido pelo Facebook. Por tais motivos, não vejo responsabilidade deste réu.

Todavia, é ressaltado o dever de zelo e empenho das instituições financeiras na adoção de cautelas a fim de prevenir e combater fraudes de toda sorte contra seus clientes. Não pode encontrar acolhida no Poder Judiciário as alegações de que a responsabilidade pelo ilícito reportado é sempre exclusivo do consumidor mesmo quando ele tenha comunicado rapidamente às administradoras de cartão ou a central de atendimento ao cliente acerca do furto, roubo ou golpe ocorrido e pelo fato carregar consigo as senhas bancárias. O efeito disso seria desamparar quem é verdadeiramente hipossuficiente nas relações de consumo. Entendimento consolidado no REsp. 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, conforme entendimento do STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da fornecedora pelo defeito do serviço prestado.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, §2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço, nos seguintes termos:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. - grifei. Desta forma, não restam dúvidas de que é aplicável às operações bancárias o Código de Defesa do Consumidor, entendimento, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 297, in verbis:

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Portanto, a responsabilidade contratual do banco é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. - grifei.

Trata-se, assim, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, consoante doutrina de Sérgio Cavaliere Filho "(...) todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor".

Portanto, os requisitos para a configuração da responsabilidade são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o

dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em tela, não estamos aplicando responsabilidade objetiva, mas estamos discutindo a falha na prestação de serviços, notadamente no que se refere ao dever de segurança.

No presente caso, é incontroverso que a autora caiu em um golpe, mas a ocorrência de fatos desencadeados por terceiros não elide a responsabilidade do banco, já que se trata de acontecimento inserido no risco do empreendimento e de golpe já conhecido pelas instituições financeiras, as quais deveriam estar desenvolvendo mecanismos para impedir a perpetração dessa modalidade criminosa.

É certo que o banco não tem como questionar todo e qualquer crédito realizado na conta corrente. Todavia, ao ser informado da ocorrência do golpe ou do depósito equivocado, o banco deve adotar providências a fim de que a conta seja utilizada para fins fraudulentos ou para que terceiros não sofram indevido prejuízo com sua utilização. Lembre-se que o princípio da função social do contrato obriga que os contratantes não permitam que a contratação cause ou contribua para que terceiros sejam prejudicados com a execução do contrato.

A autora narra que comunicou o banco através do protocolo 2022061301467493 sobre a ocorrência do golpe antes mesmo do correntista saber do crédito de forma que o réu teve condições de bloquear o valor para que a autora pudesse abrir uma disputa com o beneficiário. Todavia, o réu permaneceu inerte. Sequer consultou a existência de saldo na conta ou indagou o correntista sobre a o crédito recebido, ou seja, não adotou qualquer providência para evitar ou minimizar que terceiro sofresse prejuízo.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ("Facebook Brasil"), e julgo procedente a ação em face de BANCO ORIGINAL S.A., condenando este réu a pagar R\$ 13870,00 corrigidos monetariamente pela tabela de atualização de débito judiciais adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 1/2/2022, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, julgando extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95) contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e vir acompanhado do preparo. Conforme o art. 42, § 1º, da Lei n.

9.099/1995, fica facultado o recolhimento do preparo em até 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Frisa-se que, de acordo com o Comunicado nº 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, "o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente". Assim, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e dos Comunicados nº 1530/2021 e 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do eg. TJSP, o preparo compreenderá:

a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);

b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado da condenação ou da causa, se não houver condenação, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$610,28);

c) as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/AR: guia do FEDTJ – código 120-1; diligências do Oficial de Justiça: guia GRD; taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados: guia do FEDTJ, código 434-1; etc).

O prazo de execução voluntária da condenação em dinheiro fixada na sentença é de 15 dias contados desde o trânsito em julgado da sentença, fluindo independentemente de nova intimação. Decorridos, serão aplicado multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.

Observo que o não acolhimento das teses apresentadas, ou da interpretação pretendida sobre as provas coligidas aos autos não implica em obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Desse modo, o manejo de embargos de declaração para rediscutir tais questões corresponde a conduta temerária passível de reconhecimento de litigância de má-fé P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Rubens Hideo Arai
Juiz de Direito